



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE QUATTORDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -
SPECIALIZZATA IMPRESA "A" CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Caterina Macchi

Presidente

dott.ssa Anna Bellesi

Giudice Relatore

dott.ssa Alima Zana

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **24782/2018** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. SABINO LAUDADIO e dell'avv. ALBERTO SAGGIOMO, presso i quali è elettivamente domiciliata in Milano, Via Bigli, 21, per delega in atti

ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. DAVIDE MOSCUZZA e dell'avv. FILIPPO MARTINEZ, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Porta Vittoria, 28 presso lo studio Martinez&Partners, per delega in atti

CONVENUTA

CONCLUSIONI

ATTRICE

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, reietta ogni avversa pretesa, deduzione e richiesta:

A) Nel merito condannare *Controparte_1* allo svincolo della fideiussione costituita con polizza n.2179402 emessa da *CP_2* il 28.8.2017 per un importo di € 421.715,00 eventualmente con disapplicazione dell'art.11 del contratto in essere inter partes, poiché invalido e inefficace;

e ricorrendone eventualmente i presupposti ex art. 633 cpc, emettere ordinanza ingiuntiva ex art. 186 ter cpc finalizzata alla riconsegna/svincolo della polizza fideiussoria n. 2179402

B) Sempre nel merito:

1. Accertare e dichiarare, in relazione agli accadimenti ed alle circostanze denunciate in premessa, ai sensi dell'art. 1455 c.c. il grave inadempimento di *Controparte_1* agli obblighi assunti con il contratto n.20171462113 del 25.10.2017 nei confronti dell'attrice, consistito nella condotta sopra descritta;

2. Accertare e dichiarare, anche in relazione agli accadimenti ed alle circostanze denunciate in premessa, il tutto previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi ed assunti dalla committente in violazione degli obblighi contrattuali e di legge - anche ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 20.03.1865 n. 2248 all. E - l'illegittimità della risoluzione del contratto inter partes n. 20171462113 del 25.10.2017, disposto con nota prot. 79562 del 9.3.2018, per difetto dei presupposti e, per l'effetto, pronunciare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., la risoluzione contrattuale per inadempimento di *Controparte_1* con conseguente addebito della responsabilità in capo al predetto ente;

3. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni da mancato utile, per un importo pari ad € 401.504,40 (pari al 12% di euro 3.345.869,97, fatturato residuo contrattuale), condannando - per l'effetto - *Controparte_1* al pagamento di detto importo, maggiorato di interessi e rivalutazione monetaria fino al saldo, a favore dell'attrice stessa;

4. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento del cd. "danno emergente", per un importo pari ad € 84.350,00, per le spese approntate per la partecipazione alla gara cui ha fatto seguito il contratto poi risolto dalla committente, o alla diversa somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di dover corrispondere ai sensi dell'art. 1226 c.c., condannando - per l'effetto - *Controparte_1* al pagamento di detto importo a favore dell'attrice;

5. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento del cd. "danno emergente", per l'ulteriore importo pari a complessivi € 151.139,55 - per i costi sostenuti per i lavori strutturali dello stabilimento di produzione e la costituzione delle polizze assicurative, necessarie per l'avvio della fornitura e per la prosecuzione della stessa fino alla naturale scadenza contrattuale – o alla diversa maggior somma che l'Ecc.mo Tribunale riterrà di

dovere corrispondere ex art. 1226 c.c., condannando, per l'effetto, *Controparte_1* [...] al pagamento di detto importo a favore dell' attrice;

6. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento del cd. "danno emergente", per l'ulteriore importo di € 582.655, pari al corrispettivo contrattuale dei contratti con i fornitori dei prodotti da lavorare ed oggetto delle prestazioni d'appalto, condannando, per l'effetto, *Controparte_1* al pagamento di detto importo a favore dell'attrice medesima;

7. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni da mancato potenziamento dei requisiti esperienziali che sicuramente sarebbero stati conseguiti a servizio ultimato e spendibili in future gare, pari a complessivi € 168.686,00, ovvero alla somma che in via d'equità ritenga di dover stabilire il Tribunale, condannando - per l'effetto - *Controparte_1* al pagamento di detto importo a favore dell'attrice;

8. Accertare e dichiarare il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni all'immagine ingiustamente subiti dall'impresa, per un importo pari ad € 200.000, ovvero alla somma che in via d'equità ritenga di dover stabilire il Tribunale, condannando - per l'effetto - *Controparte_1* al pagamento di detto importo a favore dell'attrice;

9. Accertare e dichiarare - se del caso - l'inapplicabilità e/o comunque vessatorietà, per tutte le ragioni svolte nella parte motiva del presente atto, delle clausole ex artt. A.13 e A.14 del Capitolato e dell'art. 16 del contratto che ne fa richiamo;

10. Respingere ogni avversa istanza ed eccezione, formulata anche in via riconvenzionale dalla comparente;

11. Condannare *Controparte_1* in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione agli antistatari avvocati.

Sul piano istruttorio:

- Istanza di Consulenza Tecnica d'Ufficio

Si chiede disporsi Consulenza Tecnica d'Ufficio per l'accertamento dei profili tecnici correlati alle richieste avanzate dall'attrice, ai fini dell'imputabilità della risoluzione contrattuale a fatto e/o colpa dell'ente appaltante e per la quantificazione degli importi oggetto delle domande avanzate in citazione, il tutto formulando i seguenti quesiti da rivolgere al nominando ausiliario:

1) accerti il CTU se la natura e quantità delle "non conformità/contestazioni opposte dalla committente *Controparte_1* ai fini della risoluzione contrattuale fossero idonee, su piano della proporzione e rilevanza, a fondare un complessivo giudizio di inaffidabilità dell'appaltatrice nell'ambito della esecuzione del rapporto;

2) accerti il CTU l'incidenza delle predette "non conformità"/ contestazioni sul complessivo volume delle forniture effettuate da *Parte_1* come contrattualmente previste;

3) Accerti il CTU se le circostanze poste a base della “non conformità”/contestazioni opposte dalla committente fossero imputabili a complessiva grave negligenza dell’impresa piuttosto che ad inconvenienti occasionali, verificabili secondo l’id quod plerumque accidit in esecuzione di appalti analoghi a quello per cui è causa e caratterizzati da una fornitura/somministrazione quotidiana di notevoli quantità di prodotti;

- Istanza di libero interrogatorio

Sui capi di cui alla parte di fatto della citazione, si chiede ammettersi libero interrogatorio del legale rapp.te della impresa attrice, il sig. *Parte_2* nato a Torino l’11.08.1954, con domicilio eletto alla via Valle S. Bartolomeo n. 37- 15122 Alessandria.

- Istanza di ammissione alla prova testimoniale

Si chiede di essere ammessi ai seguenti capitoli di prova testimoniale, tutti preceduti dalla locuzione “vero è che”:

1) Vero è che in data 29.1.2018, quando presso lo stabilimento produttivo in Prato Sesia si tenne la visita ispettiva del *Organi* di Torino, detto organo si limitò a contestare, relativamente alle linee produttive che interessavano la fornitura a *Controparte_1* [...] un’episodica e minimale infiltrazione d’ acqua/gocciolio?

2) Vero è che *Parte_1* subito dopo detta contestazione, risolse la problematica nello spazio di poche ore e comunque in tempo utile a non condizionare la fornitura in oggetto?

3) Vero è che con analoga sollecitudine vennero risolte anche le altre problematiche riscontrate dal NAS?

4) Vero è che l *Parte_3* non ha mai trasmesso via PEC all’impresa la nota prot. 5585 del 30.1.2018 e che la stessa è stata inviata, per vie brevi, solo dopo la realizzazione di tutti gli interventi necessari a rimuovere gli inconvenienti certificati dal *Organi* il 29.1.2018 e, comunque, dopo il 2.2.2018, data in cui detta *Parte* certificò l’avvenuta esecuzione delle azioni correttive da parte dell’impresa?

5) Vero è che in data 8.11.2017, alle ore 21, presso lo stabilimento produttivo in Prato Sesia, si tenne un audit/sopralluogo “a sorpresa” dei tecnici di *Controparte_1*, che non contestarono alcunché alla ditta?

6) Vero è che in data 5.2.2018, alle ore 19, presso lo stabilimento produttivo in Prato Sesia, si tenne un audit senza sopralluogo dei tecnici di *Controparte_1*, che non contestarono alcunché alla ditta?

Si indicano quali testi i sigg.ri:

a) *Testimone_1* quale Direttore della produzione di tutti gli stabilimenti - nato a Torino il 21.08.1969 - sui capitoli di prova n. 2), 3), 4) e 6);

- b) *Testimone_2* quale dipendente - nata a Gattinata (VC) il 13.08.1975 - sul capitolo di prova n. 6);
- c) *Testimone_3* quale responsabile della produzione/tecnico - nato ad Asti il 24.07.1974 - sui capitoli di prova n. 1), 2), 3) e 4);
- d) *Testimone_4* quale dipendente - nata a Borgosesia (VC) il 19.03.1990 - sui capitoli di prova n. 5) e 6);
- e) *Testimone_5* , quale dipendente - nato a Catania il 30.06.1967 – sul capitolo di prova n. 5);
- f) *Tes_6* quale dipendente - nato a Nova Feltria (RN) il 25.07.1970 - sul capitolo di prova n. 5);
- g) *Testimone_7* , quale responsabile dello stabilimento in Prato Sesia - nato ad Aggus (SS), il 10.12.1961 - sul capitolo di prova n. 1).

- Istanza di ammissione alla prova contraria

Nella denegata ipotesi di accoglimento delle richieste di prova testimoniale così come formulate ex adverso, si chiede di essere ammessi alla prova contraria su tutti i capi di prova testimoniale che l'Ill.mo Giudice dovesse ammettere, a mezzo dei testi indicati dall'attrice nella propria memoria n. 2 ex art. 183, VI comma, cpc, oltre che con gli stessi testi di controparte”.

CONVENUTA

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito:

In via preliminare:

- accertare e dichiarare per i motivi esposti in narrativa la tardività e/o l'inammissibilità ai sensi dell'art. 183, c.p.c., delle domande formulate da *Parte_1* all'udienza del 16 ottobre 2018;

In via principale:

- accertare e dichiarare in via riconvenzionale per i motivi esposti in atti il grave inadempimento di *Parte_1* ai sensi dell'art. 1455 c.c., alle obbligazioni sulla stessa gravanti nei confronti di *Controparte_1* in forza del contratto n. 2017462113, del 25 ottobre 2017, per la fornitura di pane e prodotti derivati per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze;

- per l'effetto, sempre in via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione ai sensi degli artt. 108 D.Lgs. n. 50/2016, 1453 ss. c.c., del contratto n. 2017462113, sottoscritto il 25 ottobre 2017 tra *Controparte_1* e *Parte_1* per la fornitura di pane e prodotti derivati per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze, per grave inadempimento di *Parte_1*

- rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte le domande proposte da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o in

quanto indimostrate, ivi comprese quelle formulate all'udienza del 16 ottobre 2018 nella non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenerle ammissibili.

In via subordinata:

- accertare e dichiarare in via riconvenzionale l'inadempimento di *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ai sensi dell'art. A.13.5 lettere (m) e (n) del Capitolato Speciale di Appalto relativo al contratto n. 2017462113, del 25 ottobre 2017, per la fornitura di pane e prodotti derivati per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze, per i motivi illustrati in atti;
- per l'effetto, sempre in via riconvenzionale, dichiarare la risoluzione ai sensi degli artt. 1456 c.c. e A.13.5 lettere (m) e (n) del Capitolato Speciale di Appalto, del contratto n. 2017462113, sottoscritto il 25 ottobre 2017 tra *Controparte_1* e *Parte_1* [...] per la fornitura di pane e prodotti derivati per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze per grave inadempimento di *Parte_1*
- rigettare, comunque ed in ogni caso, tutte le domande proposte da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* in quanto infondate in fatto ed in diritto, ivi comprese quelle formulate all'udienza del 16 ottobre 2018 nella non creduta ipotesi in cui Codesto Ecc.mo Tribunale dovesse ritenerle ammissibili.

In punto di spese:

con vittoria di compensi e spese di causa.

Con espressa riserva di agire nei confronti di *Parte_1* per il risarcimento, di tutti i danni patiti e patienti da *Parte_4* causati dal grave inadempimento di *Parte_1* alle obbligazioni derivanti dal contratto n. 2017462113, sottoscritto il 25 ottobre 2017 tra *Controparte_1* e *Parte_1* per la fornitura di pane e prodotti derivati per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze, nonché con riserva di escutere la polizza fideiussoria n. 2179402, emessa da *CP_2* il 28 agosto 2017, per l'importo di €421.715,00, a garanzia del corretto adempimento da parte di *Parte_1* delle obbligazioni dedotte nel suddetto contratto

In via istruttoria:

- si chiede l'accoglimento dei capitoli di prova per testimoni già formulati nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., del 14 dicembre 2018, e di seguito ritrascritti:

1. vero che in data 11 settembre 2017 nel pane consegnato da *Parte_1* a [...] *Controparte_1* durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un frammento di carta, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8a e la documentazione fotografica sub doc. 8a2 che si rammostrano entrambi al teste;
2. vero che in data 10 ottobre 2017, all'interno del pane consegnato da *Parte_1* a *Controparte_1* durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto materiale puntiforme scuro, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione

di non conformità sub doc. 8e e la documentazione fotografica sub doc. 8e2 che si rammostrano entrambi al teste;

3. vero che in data 25 ottobre 2017 all'interno di un panino consegnato da *Parte_1* [...] a *Controparte_1* durante la somministrazione del pasto, è stato rinvenuto un capello, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8e e la documentazione fotografica sub doc. 8e2 che si rammostrano entrambi al teste;

4. vero che in data 25 ottobre 2017, durante la somministrazione del pasto, è stato rinvenuto un insetto adeso alla superficie di un panino consegnato da *Parte_1* a Milano *Controparte_1* ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8e e la documentazione fotografica sub doc. 8e2 che si rammostrano entrambi al teste;

5. vero che in data 27 ottobre 2017, durante la somministrazione del pasto, è stato rinvenuto un insetto adeso alla superficie di un panino consegnato da *Parte_1* a Milano *Controparte_1* ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8e e la documentazione fotografica sub doc. 8e2 che si rammostrano entrambi al teste;

6. vero che *Parte_1* ha affermato che il 27 novembre 2017 ha consegnato a *Controparte_1* il pane su pedane sporche, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8d che si rammostra al teste;

7. vero che in data 29 novembre 2017 nel pane consegnato da *Parte_1* a [...] *Controparte_1* presso il centro cucina *Pt_5* sito in Via Giusti n. 15, durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un corpo estraneo di natura non identificata adeso ad un panino ed impastato di mollica, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8f e la documentazione fotografica sub doc. 8f2 che si rammostrano entrambi al teste;

8. vero che in data 30 novembre 2017, tra il pane consegnato da *Parte_1* a *Controparte_1* durante la somministrazione del pasto presso la scuola primaria *Controparte_3* sita in Via Vincenzo Russo n. 27 Milano, sono stati rinvenuti insetti adesi alla superficie del pane all'interno di due sacchetti chiusi, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8f e la documentazione fotografica sub doc. 8f2 che si rammostrano entrambi al teste;

9. vero che in data 1° dicembre 2017 nel pane consegnato da *Parte_1* a [...] *Controparte_1* presso il centro cucina dora *Org_2*, sito in Via Dora Baltea n. 16 Milano, durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un corpo estraneo di colore verde adeso ad una focaccia ancora sigillata, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità 78772 sub doc. 8f e la documentazione fotografica sub doc. 8f2 che si rammostrano entrambi al teste;

10. vero che in data 1° dicembre 2017 nel pane consegnato da *Parte_1* a *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_3* di Nemi sito in Via Uccelli di Nemi n. 54 Milano, durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un corpo estraneo di natura metallica, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità 78772 sub doc. 8f e la documentazione fotografica sub doc. 8f2 che si rammostrano entrambi al teste;
11. vero che in data 12 dicembre 2017 *Parte_1* ha consegnato a [...] *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_4* sito in Via Sammartini n. 73 Milano, il pane su bancali sporchi, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8g che si rammostra al teste;
12. vero che in data 13 dicembre 2017 nel pane consegnato da *Parte_1* a [...] *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_5* sito in Via Bresciani -Turrone Palmanova, durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un pezzo di pizza all'interno di un sacchetto di pane, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8h che si rammostra al teste;
13. vero che in data 13 dicembre 2017 all'atto del ricevimento della merce presso il centro cucina *Org_4* sito in Via Sammartini n. 73 Milano, sono stati rinvenuti dei pezzi di plastica rossa all'interno di tre sacchetti di pan grattato consegnati da *Parte_1* [...] a *Controparte_1* ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8i e la documentazione fotografica sub doc. 8i2 che si rammostrano entrambi al teste;
14. vero che in data 15 dicembre 2017 *Parte_1* ha consegnato a [...] *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_4* sito in Via Sammartini n. 73 Milano, il pane su bancali sporchi, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8g che si rammostra al teste;
15. vero che in data 8 gennaio 2018 all'interno di un panino consegnato da *Parte_1* [...] a *Controparte_1* durante la somministrazione del pasto, è stato rinvenuto un corpo estraneo di plastica nera rigida della lunghezza di 3,5 cm, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8h e la documentazione fotografica sub doc. 8h2 che si rammostrano entrambi al teste;
16. vero che in data 11 gennaio 2018 *Parte_1* ha consegnato a [...] *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_4* sito in Via Sammartini n. 73 Milano, il pane su bancali sporchi, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8l che si rammostra al teste;
17. vero che in data 24 gennaio 2018 all'interno di un panino consegnato da *Parte_1* [...] a *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_6* sito in Via Colleoni angolo Via Gattamelata Milano, durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un capello, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non

conformità sub doc. 8m e la documentazione fotografica sub doc. 8m2 che si rammostrano entrambi al teste;

18. vero che in data 30 gennaio 2018 nei crostini con farina integrale biologica lotto del 09/11/2017, consegnati da *Parte_1* a *Controparte_1* durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un corpo estraneo di plastica nera della lunghezza di 2 cm, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8m e la documentazione fotografica sub doc. 8m2 che si rammostrano entrambi al teste;

19. vero che in data 30 gennaio 2018 sulla superficie di un panino consegnato da *Parte_1* a *Controparte_1* presso il centro cucina *Pt_5* sito in Via Giusti n. 15, Milano, durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un corpo estraneo bruno, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8n e la documentazione fotografica sub doc. 8n2 che si rammostrano entrambi al teste;

20. vero che in data 1° febbraio 2018 all'interno dei grissini con lotto S0293L1 consegnati da *Parte_1* a *Controparte_1* durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un frammento di filo metallico, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8m e la documentazione fotografica sub doc. 8m2 che si rammostrano entrambi al teste;

21. vero che in data 2 febbraio 2018 durante la somministrazione del pasto in sette panini consegnati da *Parte_1* a *Controparte_1* sono stati rinvenuti dei filamenti di colore bianco con materiale granuloso adeso di colore azzurro, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8o e la documentazione fotografica sub doc. 8o2 che si rammostrano entrambi al teste;

22. vero che in data 2 febbraio 2018 in due panini consegnati da *Parte_1* a *Controparte_1* durante la consumazione del pasto sono stati rinvenuti dei frammenti di plastica bianca rigida della lunghezza di 3 cm ed 1 cm provenienti da una impastatrice, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8o e la documentazione fotografica sub doc. 8o2 che si rammostrano entrambi al teste;

23. vero che in data 2 febbraio 2018 *Parte_1* ha consegnato a [...] *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_4* sito in Via Sammartini n. 73 Milano, il pane su bancali sporchi, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8p che si rammostra al teste;

24. vero che in data 9 febbraio 2018 all'interno di un panino consegnato da *Parte_1* [...] a *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_6* sito in Via Colleoni angolo Via Gattamelata Milano è stato rinvenuto un frammento di filo elettrico, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8q e la documentazione fotografica sub doc. 8q2 che si rammostrano entrambi al teste;

25. vero che il 9 febbraio 2018 nel pane consegnato da *Parte_1* a [...] *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_7* Giustizia n. 6 sito in Via De Marchi - Via Della Giustizia Milano, durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un ragno all'interno del sacchetto di un panino sigillato, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8q e la documentazione fotografica sub doc. 8q2 che si rammostrano entrambi al teste;

26. vero che in data 30 gennaio 2018 sulla superficie di un panino consegnato da *Parte_1* a *Controparte_1* durante la somministrazione del pasto presso il *CP_4* sito in Via Pusiano n. 2 Milano, è stato rinvenuto un corpo estraneo di colore bruno contenente un frammento di fibra sintetica, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8q che si rammostra al teste;

27. vero che in data 14 febbraio 2018 all'interno di un panino consegnato da *Parte_1* [...] a *Controparte_1* presso il centro cucina *Org_8* sito in Via Bresciani Turrone - Palmanova, durante la somministrazione del pasto è stato rinvenuto un filo di tessuto nero, ed a seguito di ciò è stata inviata la missiva di contestazione di non conformità sub doc. 8r e la documentazione fotografica sub doc. 8r2 che si rammostrano entrambi al teste;

Sui capitoli dal n. 1 al n. 27 si indicano a testi:

- *Testimone_8*, domiciliato per l'ufficio presso il *Organizzazione_9* [...], Via Porpora n. 10, 20131 Milano;
- *Tes_9* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Testimone_10*, domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;

Sul solo capitolo n. 19, in aggiunta agli altri testi si indica anche la sig.ra:

- *Tes_9* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;

28. vero che durante la visita del 7 novembre 2017 presso lo stabilimento di *Parte_1* [...] sito in Prato Sesia, gli incaricati di *Controparte_1* signori *Per_1* [...], *Persona_2*, *Persona_3*, *Persona_4* e *Persona_5*, hanno richiesto un aumento delle frequenze di pulizia dei locali di produzione e delle linee di lavorazione, come da doc. 9 che si rammostra al teste;

29. vero che gli organi di movimentazione meccanica della linee di trascinamento delle linee di produzione dello stabilimento di *Parte_1* sito in Prato Sesia, visionati durante la visita del 7 novembre 2017 dei signori *Persona_1*, *Persona_2* [...], *Per_3*, *Persona_4* e *Persona_5*, incaricati di *Controparte_1*

sporcavano i panini presenti su dette linee lasciando residui grigi e corpuscoli bruni sulla relativa superficie, come da doc. 9 che si rammostra al teste;

30. vero che in occasione della visita del 7 novembre 2017 effettuata dagli incaricati di

Controparte_1 signori *Persona_1*, *Persona_2* *Persona_3*
Persona_4 e *Persona_5*, presso lo stabilimento di *Parte_1* sito in Prato Sesia, il metal detector delle linee di produzione di *Parte_1* individuava solo alcuni dei campioni metallici utilizzati come prova del relativo funzionamento, come da doc. 9 che si rammostra al teste;

31. vero che la maglia di trascinamento dei panini dopo la formatura e la catena del tunnel di cottura delle linee di produzione dello stabilimento di *Parte_1* sito in Prato Sesia, visionati durante la visita del 7 novembre 2017 degli incaricati di [...]

Controparte_1 signori *Persona_1*, *Persona_2* *Persona_3* [...]
Per_4 e *Persona_5*, erano privi di alcune componenti, come da doc. 9 che si rammostra al teste;

32. vero che durante la visita degli incaricati di *Controparte_1* signori *Persona_1*, *Persona_2* *Persona_3* *Persona_4* e *Persona_5*, del 7 novembre 2017 presso lo stabilimento di *Parte_1* sito in Prato Sesia, gli incaricati di *Parte_1* riferivano la mancata esecuzione di analisi della qualità della farina e di specifiche circa il ritrovamento di insetti, come da doc. 9 che si rammostra al teste;

Sui capitoli dal n. 28 al n. 32 si indicano a teste:

- *Persona_1*, domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;

Persona_2 domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;

- *Persona_3* domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;

- *CP_5* domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;

- *Persona_5*, domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;

33. vero che il 31 gennaio 2018 presso la sede di Milano *Controparte_1* sita in Milano, Via Quaranta n. 41, aveva luogo un incontro tra la dott.ssa *Persona_6* il dott. *Persona_7*, il dott. *Persona_8* la dott.ssa *Persona_2* il sig. *Controparte_6* *Controparte_1* ed i signori *Tes_6* *Tes_1* e [...]
Controparte_7

34. vero che in occasione dell'incontro tenutosi il 31 gennaio 2018 presso la sede di *Controparte_1* sita in Milano, Via Quaranta n. 41, tra la dott.ssa *Per_6*

Per_6 il dott. *Persona_7*, il dott. *Persona_8* la dott.ssa *Persona_2*
[...] il sig. *Persona_3* di *Controparte_1* ed i signori *Tes_6* *Tes_1* e
Controparte_7 i presenti alla riunione hanno parlato del rinvenimento del
corpo estraneo avvenuto in data 30 gennaio 2018, e indicato nella missiva di
contestazione di non conformità sub doc. 8n che si rammostra al teste;

35. vero che in occasione dell'incontro tenutosi il 31 gennaio 2018 presso la sede di
Controparte_1 sita in Milano, Via Quaranta n. 41, tra la dott.ssa [...] *Per_6*
il dott. *Persona_7*, il dott. *Persona_8* la dott.ssa *Persona_2*
[...] il sig. *Persona_3* di *Controparte_1* ed i signori *Tes_6* *Tes_1*
[...] e *CP_8* *Parte_1* i presenti alla riunione hanno stabilito che il
1° febbraio 2018 *Parte_1* avrebbe somministrato dei grissini e che la fornitura di
pane sarebbe ripresa il 2 febbraio 2018;

Sui capitoli dal n. 33 al n. 35 si indicano:

- *Persona_6* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via
B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_7*, domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B.
Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_2* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B.
Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_3* domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B.
Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- sig. *Tes_6* domiciliato per l'ufficio presso *Parte_1* Via Valle San Bartolomeo
n. 37, 15122 Alessandria (AL);
- *Testimone_1* domiciliato per l'ufficio presso *Parte_1* Via Valle San
Bartolomeo n. 37, 15122 Alessandria (AL);
- *Parte_2* domiciliato per l'ufficio presso *Parte_1* Via Valle San
Bartolomeo n. 37, 15122 Alessandria (AL);

36. vero che il 5 febbraio 2018 la dott.ssa *Persona_6* il dott. *Persona_7*,
il dott. *Per_7* *Persona_8* la dott.ssa *Persona_2* il sig. *Persona_3* di [...] *Controparte_1*
effettuavano un sopralluogo presso lo stabilimento di *Parte_1*
[...] sito in Prato Sesia (NO), Via Matteotti n. 131;

37. vero che in occasione del sopralluogo effettuato il 5 febbraio 2018 presso lo
stabilimento di *Parte_1* sito in Prato Sesia (NO), Via Matteotti n. 131, gli
incaricati di *Controparte_1* dott.ssa *Persona_6* dott. *Per_7*
[...] , dott. *Persona_8* dott.ssa *Persona_2* e sig. *Persona_3*
venivano ricevuti dal sig. *Parte_6* *Parte_1*

38. vero che in occasione del sopralluogo effettuato il 5 febbraio 2018 presso lo
stabilimento di *Parte_1* sito in Prato Sesia (NO), Via Matteotti n. 131, dagli

incaricati di *Controparte_1* dott.ssa *Persona_6* dott. *Per_7* [...], dott. *Persona_8* dott.ssa *Persona_2* e sig. *Persona_3* il verbale di ispezione dei NAS n. 114/1-1 era poggiato sopra il tavolo della sala riunioni ove gli incaricati di *Controparte_1* venivano ricevuti;

Sui capitoli dal n. 36 al n. 38 si indicano:

- *Persona_6* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_7*, domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_2* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_3* domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- sig. *Tes_3* domiciliato per l'ufficio presso *Parte_1* Via Valle San Bartolomeo n. 37, 15122 Alessandria (AL).

*

- si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie formulate dalla controparte per i motivi espressi nella memoria n. 3 del 28 dicembre 2018 ed all'udienza del 13 febbraio 2019.
- nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione di alcuno dei capitoli formulati dalla controparte, si chiede di essere ammessi a prova contraria sugli stessi capitoli avversari, indicando quali testi:

- *Tes_9* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_1*, domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_2* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_3* domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *CP_5* domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_5*, domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_6* domiciliata per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano;
- *Persona_7*, domiciliato per l'ufficio presso *Controparte_1* Via B. Quaranta n. 41, 20139 Milano.”

Ragioni della decisione

1. La *Parte_1* con citazione notificata in data 8 maggio 2018, ha convenuto in giudizio la *Controparte_1* deducendo di aver sottoscritto con la convenuta, in data 25 ottobre 2017, il contratto d'appalto rep. n. 2017/462113, per un importo contrattuale di € 4.217.150,00 oltre i.v.a.

La stipulazione seguiva l'aggiudicazione del 29 agosto 2017, intervenuta all'esito di gara pubblica, bandita in data 1 agosto 2017 per l'affidamento della *“fornitura di pane e prodotti derivati, per il servizio di refezione scolastica e altre utenze dal 07.09.2017 al 31.08.2019 (gara CIG: P.IVA_3)”*,

L'attrice assume che:

- con nota prot. 79307 del 14 febbraio 2018, la committente *Controparte_1* invitava l'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108, III comma, D.lgs 50/2016, a produrre le proprie controdeduzioni in ordine ad alcune contestazioni ivi svolte (*“non conformità”* di servizio, merceologiche, igienico-sanitarie e legali);
- con atto del 28 febbraio 2018 ex art. 108, III comma, D.lgs 50/2016, *Parte_1* controdeduceva puntualmente in ordine alle contestazioni dell'ente, che riteneva infondate e comunque irrilevanti ai fini della disponenda risoluzione contrattuale, e concludeva chiedendo l'archiviazione del procedimento ai fini dell'immediata ripresa del servizio, *medio tempore* ingiustificatamente sospeso dalla committente;
- con provvedimento prot. 79562 del 9 marzo 2018, la committente *Controparte_1*, valutate negativamente le controdeduzioni dell'impresa, dichiarava la risoluzione in danno per inadempimento dell'appaltatore del contratto stipulato in data 25 ottobre 2017, *“con riserva di escutere la cauzione ai sensi degli artt. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e 11 e 18 del contratto”*;

Alla luce di tali premesse, *Parte_1* sostiene che la risoluzione anticipata del contratto d'appalto è scelta illegittima e foriera di relevantissimi pregiudizi in danno

dell'appaltatrice, che rilevano sotto il profilo del danno, tanto patrimoniale, quanto non patrimoniale.

L'attrice chiede quindi l'annullamento o la disapplicazione dell'atto risolutivo del rapporto contrattuale, essendo imputabile a fatto e colpa della committente la risoluzione contrattuale, ed evidenzia che l'illegittimità della scelta di *Controparte_1* di risolvere il contratto rileva sotto svariati profili, così riassunti:

- a) insussistenza dei presupposti della risoluzione contrattuale e grave inadempimento dell'impresa appaltatrice – violazione art. 108 D.lgs 50/2016 artt. 1453, 1455 e 1456 c.c. – violazione artt. 1559 e ss. c.c. - sproporzione;
- b) non operatività della clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. e comunque sua illegittimità e/o carenza dei presupposti – vessatorietà ex art. 1341 c.c.;
- c) violazione del contratto e del Capitolato Speciale d'appalto nonché dei canoni della buona fede e della leale cooperazione nella esecuzione del contratto d'appalto (artt. 1175 e 1375 c.c.).

2. La convenuta si è costituita con comparsa depositata in data 20 settembre 2018, contestando gli assunti della controparte ed evidenziando che Milano *Controparte_1* è una società a totale capitale pubblico costituita dal *Org_9*, come fosse un proprio organo, per gestire il servizio di ristorazione nel territorio comunale.

Ha poi rilevato che, con bando del 26 giugno 2017, la stessa aveva indetto una gara aggiudicatasi, in seguito, da *Parte_1*. Le condizioni e le modalità di svolgimento dell'appalto venivano disciplinate nel contratto e dal Capitolato Speciale di Appalto così come dalle schede tecniche allegate, che indicavano specificamente come ciascun prodotto dovesse essere realizzato. Allo stesso tempo, alla stazione appaltante era riconosciuta la facoltà di effettuare verifiche rispetto a tutte le fasi di produzione (art. A.13 del Capitolato). Secondo le regole stabilite, una volta rilevata una violazione, *Controparte_1* avrebbe dovuto comunicarla all'appaltatore che poteva, entro un termine, controdedurre. All'esito della valutazione delle osservazioni, il direttore dell'esecuzione del contratto avrebbe proceduto, a seconda dei casi, all'applicazione

della penale o all'archiviazione della contestazione (art. A.13.4 del Capitolato). Infine, l'art. 16 del contratto e l'art. A.13.5 del Capitolato disciplinavano la risoluzione contrattuale e, in aggiunta rispetto a quanto previsto dall'art. 108 D.lgs. 50/2016 e dall'art. 1453 c.c., individuavano altresì alcune ipotesi di clausole risolutive espresse ex art. 1456 c.c.

In primo luogo, precisa la convenuta, fin dalle prime forniture, *Controparte_1* aveva riscontrato delle non conformità costanti nei prodotti offerti da *Parte_1* e aveva applicato delle penali. In particolare erano state rilevate non conformità di carattere igienico-sanitario e non conformità relative alle disposizioni concernenti peso, etichettatura e consegna.

Il 30 gennaio 2018 *Controparte_1* aveva ricevuto una segnalazione avente ad oggetto il pane fornito da *Parte_1*, nel quale era stata riscontrata la presenza di corpi estranei e un odore anomalo; per tali ragioni, la committente aveva bloccato la somministrazione per la giornata successiva. In data 2 febbraio 2018 la fornitura di pane era stata ripresa. In data 5 febbraio 2018 *Controparte_1*, durante un sopralluogo presso lo stabilimento di Prato Sesia dell'attrice, aveva appreso accidentalmente che il 29 gennaio 2018, i Carabinieri del N.A.S., a seguito di un'ispezione, avevano riscontrato numerose carenze igieniche e strutturali e avevano richiesto l'intervento dell'*Pt_3*. Quest'ultima, con comunicazione datata 30 gennaio 2018 aveva imposto a *Parte_1* la sistemazione delle non conformità accertate e disposto la sospensione dell'attività. In data 2 febbraio 2018 l'*Pt_3* aveva consentito la ripresa dell'attività, ma nel frattempo la produzione non si era mai realmente fermata.

A seguito dei gravi e reiterati inadempimenti, *Controparte_1*, a metà febbraio 2018, aveva intrapreso la procedura per la risoluzione del contratto di cui all'art. 108 D.lgs. 50/2016 per inadempimento dell'appaltatore. Con comunicazione del 14 febbraio 2018 *Parte_1* veniva sospesa dall'esecuzione della fornitura e riceveva le contestazioni dei relativi addebiti. L'appaltatore forniva le proprie controdeduzioni, che venivano ritenute generiche a fronte di inadempimenti specifici e gravi. Inoltre,

l'appaltatore, non avendo mai posto rimedio a dette non conformità, faceva venire meno il rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

La risoluzione del contratto è regolata dal D.lgs. 50/2016, dalle norme generali in tema di risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e seguenti c.c. nonché da quanto previsto nel contratto e nel Capitolato Speciale d'appalto. Nel caso di specie, l'interesse di *Controparte_1* alla corretta esecuzione del contratto, rispetto al quale va valutata la gravità dell'inadempimento, consiste nella fornitura di cibo conforme agli standard igienici e di sicurezza alimentare. L'inadempimento di parte attrice è consistito in plurime violazioni di obbligazioni contrattuali.

L'attrice, sostiene la convenuta, tenta di sminuire i propri inadempimenti con un calcolo della percentuale delle non conformità accertate rispetto al numero dei pasti forniti, ma tale ragionamento è errato in quanto l'art. 1455 c.c. mette in relazione la non scarsa importanza dell'inadempimento con l'interesse che il creditore ha all'esecuzione della prestazione: in questo caso a garantire un pasto buono e sano.

Si assume poi l'infondatezza della tesi di parte attrice secondo la quale la risoluzione del contratto sarebbe illegittima perché intervenuta successivamente ad una sanzione già applicata con le penali. In realtà, l'art. 1453 c.c. prevede che l'applicazione delle penali si riverberi semmai solo sul profilo del danno ma non privi mai la parte non inadempiente del diritto di risolvere il rapporto. Lo stesso art. 108 D.lgs. 50/2016 prevede che la risoluzione del contratto venga disposta, fermo restando il pagamento delle penali. Parimenti infondate sarebbero le ulteriori censure aventi ad oggetto la violazione dei canoni di buona fede e leale cooperazione.

Precisa inoltre la convenuta che la risoluzione del contratto è stata dichiarata ai sensi dell'art. 108 D.lgs. 50/2016 e dell'art. 1453 c.c., non avendo *Controparte_1* azionato le ipotesi di clausole risolutive espresse contenute nell'art. A.13.5 del Capitolato Speciale d'Appalto. *Controparte_1* ha richiamato le ipotesi di inadempimento dell'appaltatore espressamente codificate alle lettere m) e n) dell'art. A.13.5 del Capitolato alle quali le parti hanno riconosciuto efficacia risolutiva.

La convenuta chiede dunque che il Tribunale, accertato il grave inadempimento di *Parte_1*, ai sensi dell'art. 1455 c.c., alle obbligazioni sulla stessa gravanti, dichiarare la risoluzione ai sensi degli artt. 108 D. lgs. 50/16, 1453 ss. c.c., del contratto stipulato e, in subordine, accertato l'inadempimento di *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* ai sensi dell'art. A.13.5 lettere m) e n) del Capitolato Speciale di Appalto relativo al contratto n. 2017/462113, dichiarare la risoluzione ai sensi degli artt. 1456 c.c. e A.13.5 lettere m) e n) del Capitolato Speciale di Appalto del contratto medesimo.

3. All'udienza di prima comparizione del 16 ottobre 2018 la difesa di parte attrice, rilevando che in data 20 settembre 2018 la *Parte_1* si era vista rifiutare lo svincolo della polizza in garanzia, ha chiesto lo svincolo della fideiussione costituita con polizza n.2179402 emessa da *CP_2* il 28 agosto 2017 per un importo di € 421.715,00, eventualmente con disapplicazione dell'art.11 del contratto in essere tra le parti "*poiché invalido e inefficace*". La *Parte_1* ha chiesto inoltre l'inibitoria di ogni forma di escussione, anche parziale, da parte della *Controparte_1*, e quest'ultima si è opposta, eccependo la novità della domanda e la liceità della riserva di escussione della fideiussione, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del contratto.

Dopo la concessione dei termini previsti dall'art.183 sesto comma c.p.c. e il deposito delle relative memorie, la causa, senza svolgimento di attività istruttoria, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente rimessa al collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.

4. Come emerge dalla ricostruzione dei fatti sopra riassunti, che hanno dato origine alla controversia, l'oggetto del contendere è l'accertamento dell'inadempimento contrattuale dell'una o dell'altra parte, accertamento dal quale l'attrice fa discendere la richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1453 c.c. e la richiesta di risarcimento del danno, inteso quale danno emergente, da mancato utile e di immagine, e la convenuta fa discendere la richiesta di declaratoria di risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 D.lgs. n.50/2016 e 1453 e seguenti c.c. 1455.

Poiché l'attrice sostiene che *“La risoluzione anticipata del contratto d'appalto, per le motivazione che la supportano, è scelta illegittima, espressione di arbitrio”* occorre muovere dalla valutazione della correttezza dell'operato della *Controparte_1* che, con comunicazione a mezzo pec del 9 marzo 2018, ha dichiarato alla *Parte_1* *“la risoluzione in danno per inadempimento dell'appaltatore del contratto stipulato in data 25 ottobre 2017 del contratto”* (doc.2 di parte attrice e 18 di parte convenuta).

Tale decisione della committente costituisce lo sbocco del procedimento dalla stessa avviato ai sensi dell'art. 108 D.lgs. n.50/2016, all'esito del quale *Controparte_1* *“ai sensi degli artt. 108, comma 3, D.lgs 50/2016, 1453 c.c., nonché degli artt. 16 del Contratto e A.13.5 C.S.A.”* ha comunicato alla controparte la risoluzione del contratto *“con riserva di escutere la cauzione ai sensi degli artt. 103 del D.lgs n. 50 del 2016 e 11 e 18 del contratto.”*

Già dall'inizio dello svolgimento del rapporto contrattuale, che ha avuto esecuzione anticipata, a partire dai primi giorni di settembre 2017, si ha traccia di contestazioni elevate dalla committente a *Parte_1* per alcune non conformità nei prodotti da quest'ultima forniti.

In particolare, risulta dai docc. 7 e 8 di parte convenuta che, accanto a rilievi quali *“consegna errata”, “pane duro”, “peso ed etichetta non conformi”*, già in data 11 settembre 2017 è stata formulata una contestazione per la presenza di un *“Corpo estraneo da Org_10”*. Tale presenza, come si evince dal doc.8a di parte convenuta, non è stata contestata da *Parte_1*, che nella propria mail inviata il 20 settembre 2017 si scusa per *“lo spiacevole inconveniente accaduto”* e riconosce che *“si tratta di un frammento di carta” di un sacco, tagliato “con un coltello a sega, [...] che accidentalmente finiva nell'impasto”*.

Nei mesi successivi, sono seguite altre contestazioni di varia natura, anche relative alla presenza di corpi estranei quali insetti, peli/capelli, fili di tessuto, o di natura metallica o di origine non definita, per i quali sono state applicate le penali previste dal capitolato speciale d'appalto.

Dal documento n.9 di parte convenuta (verbale *audit* fornitori in data 8 novembre 2017) emerge che, presso lo stabilimento di *Parte_1* di Prato Sesia, le condizioni igienico sanitarie dei locali di produzione e delle linee di lavorazione non erano pienamente soddisfacenti. Erano presenti residui grigi sulla superficie dei panini e corpuscoli scuri all'interno degli stessi a causa degli organi di movimentazione meccanica della linea di trascinamento, che sporcavano i panini con cui entravano in contatto o che si trovavano nelle immediate vicinanze. Il *metal detector* non funzionava correttamente e non individuava alcuni campioni metallici, la maglia di trascinamento dei panini dopo la formatura e la catena del tunnel di cottura erano evidentemente usurati, non venivano eseguite analisi di verifica della qualità della farina, né sussistevano specifiche in merito al ritrovamento di insetti al momento del carico della fornitura, in quanto *Parte_1* si limitava a chiedere le analisi al fornitore.

Durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, *Controparte_1* ha ricevuto anche numerose segnalazioni degli utenti che lamentavano la cattiva qualità del pane fornito (doc. 10 di parte convenuta).

Un articolo pubblicato il 1° febbraio 2018 sul sito internet del Corriere della Sera e di Repubblica (doc. 11 di parte convenuta) documenta l'avvenuta sospensione della distribuzione del pane da parte di *Controparte_1* per la segnalazione della presenza di un "corpo estraneo" all'interno di un panino.

A tali fatti è seguito un sopralluogo presso lo stabilimento produttivo di Prato Sesia dell'appaltatrice, avendo la committente deciso di avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. A.13 del Capitolato (doc.5 di parte convenuta).

Nel corso di tale sopralluogo, *Controparte_1* avrebbe accidentalmente appreso che il 29 gennaio 2018, giorno di preparazione del pane in cui era stato rinvenuto il corpo estraneo oggetto di risonanza mediatica, il Comando dei Carabinieri per la *Org_11* della *Organizzazione_12* di Torino, aveva effettuato un'ispezione presso il laboratorio dell'appaltatrice sito in Prato Sesia, luogo di produzione del pane

oggetto del contratto, su richiesta del N.A.S. Carabinieri di Padova e del N.A.S. Carabinieri di Bologna.

Dal verbale del N.A.S., prodotto dalla convenuta quale doc.12, si evince, quanto alle condizioni igieniche riscontrate, che *“la presenza di una vastissima macchia di umidità”* aveva creato *“la precipitazione di grosse quantità di intonaco e calcinacci che cadendo finiscono sia sopra ai contenitori già pronti [...] con all’interno gli ingredienti per l’impasto [...] sia nei contenitori con la pasta destinata alle lavorazioni [...] L’intera area impastatrici presentava muffa ed affioramenti di umidità anche lungo le pareti, sopra il lavello e lungo il battiscopa ove si accertava anche massiccia presenza di sporcizia, incrostazioni, e residui di alimenti non rimossi [...] dalle ventole di areazione venivano trasportati dei corpi estranei di colore nero che si depositavano sulla superficie esterna degli impasti sopra descritti insudiciandoli. Detti corpi estranei venivano poi impastati unitamente agli ingredienti [...] e finivano all’interno delle pagnotte di pane”* (foglio n.3 del verbale).

Il verbale evidenzia che le *“gravissime carenze igienico-sanitarie e gestionali [...] non garantiscono la sicurezza degli alimenti manipolati preparati, cotti nonché detenuti/stoccati per la successiva somministrazione agli ignari consumatori finali [...] e che “lo stato attuale dell’attività” può “costituire un concreto e reale pericolo per la salute dei consumatori”, essendo “completamente assenti i requisiti igienico-sanitari – strutturali minimi previsti per la specifica attività di preparazione, manipolazione, cottura, stoccaggio e commercializzazione di sostanze alimentari”.*

A seguito del sopralluogo del N.A.S. è stato disposto il sequestro giudiziario di 2.500 Kg di preimpasto. È stata accertata anche la violazione dell’art. 5, lettere b) e d) della legge 283/1962, stante la detenzione, per il successivo utilizzo, di *“alimenti e/o materie prime insudiciate per la massiccia presenza di corpi estranei fuoriusciti dall’impianto di refrigerazione malfunzionante”.*

L Pt_3 di Pt_3 sulla base delle risultanze della verifica del N.A.S. di Torino, ha imposto con provvedimento del 30 gennaio 2018 la rimozione delle non conformità

accertate: rimozione della muffa ed eliminazione dell'umidità, pulizia della sporcizia e delle incrostazioni, sanificazione dell'impianto di ventilazione e sostituzione di un nastro trasportatore; ha disposto altresì la sospensione dell'attività fino alla realizzazione di quanto prescritto (doc. 20 di parte attrice e 13 di parte convenuta).

I fatti descritti sono stati oggetto di un esposto della **Controparte_1** alla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano in data 20 febbraio 2018 (doc. 14 di parte convenuta).

Infatti anche nei giorni successivi alla verifica dell **Pt_3** sono proseguiti gli episodi che hanno dato origine alle contestazioni della committente.

La convenuta, in particolare, ha richiamato nei propri atti le singole ulteriori non conformità rilevate: *“il 1° febbraio 2018 è stato rinvenuto un frammento di filo metallico, che **Parte_1** ha riconosciuto essere parte della rete del forno (cfr. corrispondenza non conformità 79201 sub doc. 8);*

*- in data 2 febbraio 2018 sono stati rinvenuti sette corpi estranei in altrettanti panini forniti a diverse utenze. Si è trattato di filamenti di colore bianco con materiale adesivo di colore azzurro, e di frammenti di plastica bianca che **Parte_1** ha riconosciuto provenire rispettivamente dal nastro trasportatore e dalla macchina impastatrice (cfr. corrispondenza non conformità 79184 sub doc. 8);*

- il 9 febbraio 2018 nel pane fornito sono stati rinvenuti: un ragno all'interno del sacchetto di un panino, un frammento di filo metallico, ed un frammento di fibra sintetica (cfr. corrispondenza non conformità 79283 sub doc. 8);

*- il 14 febbraio 2018 nel pane fornito è stato ritrovato un filo di tessuto nero che **Parte_1** ha riconosciuto provenire dal nastro trasportatore (cfr. corrispondenza non conformità 79383 sub doc. 8)”* (pag. 11 della comparsa conclusionale di **[...]** **CP_1**).

Successivamente a tali contestazioni, **Controparte_1** ha dato avvio alla procedura per la risoluzione del contratto disciplinata dall'art.108, terzo comma, D.lgs. n. 50/2016, inviando in data 14 febbraio 2018 comunicazione della sospensione dell'esecuzione

della fornitura, contestando i relativi addebiti e assegnando a *Parte_1* il termine di quindici giorni per presentare controdeduzioni.

Nella citata nota, gli inadempimenti contestati dalla *Controparte_1* sono così riepilogati:

“ ➤ nr. 14 NC nel mese di settembre;

- nr. 23 NC nei mese di ottobre;

➤ nr. 14 NC nel mese di novembre;

➤ nr 11 Nc nel mese di dicembre;

- nr. 23 nel mese di gennaio;

- nr. 26 al 12 febbraio.

Le NC hanno riguardato prevalentemente le seguenti aree:

➤ nr. 34 NC di servizio (ritardi di consegne, mancate consegne, ecc.);

- nr. 42 NC merceologiche (pezzatura disomogenea, difetto di prodotto, condensa nei sacchetti, colore atipico, ecc.);

➤ nr. 33 NC igienico sanitarie (corpi estranei, bancali sporchi, ecc.);

➤ nr. 7 NC legali (etichettatura errata, DDT errato, ecc.).

A fronte di tali segnalazioni, sono state richieste alla Vs. società le relative controdeduzioni che:

➤ 38 volte sono state ritenute esaustive, pertanto la pratica è stata archiviata;

- 45 volte non sono state accettate, hanno quindi generato l'applicazione di una penale, per un totale di € 10.705,05, di queste n. 33 sono relative a non conformità del prodotto sotto il profilo Igienico sanitario;

➤ 33 sono in attesa di definizione.

Le segnalazioni di mancato gradimento del pane pervenute dall'utenza, tramite la compilazione della check list di monitoraggio/valutazione del servizio (allegato E al regolamento comunale delle commissioni mensa) da parte dei Commissari *Per_9* nel

periodo compreso tra 5 settembre 2017 ed il 9 febbraio 2018, sono in totale nr. 540.” (doc. 15 di parte convenuta).

Nelle proprie controdeduzioni del 28 febbraio 2018, *Parte_1* evidenzia che il numero complessivo delle non conformità segnalate *“è assolutamente esiguo e/o marginale al cospetto dei volumi della fornitura”* e che quindi esso non giustifica l’applicazione della *“gravissima misura risolutiva ex art. 108 D.lgs. 50/2016”* (doc. 16 di parte convenuta).

Il Responsabile Unico del Procedimento, reputando non esaustive le controdeduzioni di *Parte_1* e compromesso il rapporto di fiducia tra le parti, ha proposto la risoluzione del contratto ex art. 108, terzo comma del D.lgs. n. 50/2016 (doc. 17 di parte convenuta), cui è seguita la risoluzione da parte di *Controparte_1* (doc. 18 di parte convenuta).

L’attrice in sede giudiziale ribadisce l’inidoneità delle contestazioni svolte a fondare la misura risolutiva del rapporto e pone nuovamente in evidenza l’esiguità del loro numero, sostenendo che *“il totale delle suddette non conformità (88 NC relative a presunti problemi di qualità e n. 39 NC relative ad altri aspetti non qualitativi) ha un'incidenza che, nell'ambito di n. 8.800.000 pasti somministrati dalla impresa, risulta pari ad una percentuale dello 0,0014% sul complessivo volume della fornitura!*

E nell'ambito di dette NC, quelle relative alla qualità del prodotto, erano pari allo 0,0001% [...]”. Quanto alle segnalazioni pervenute a *Controparte_1*, rileva che, *“anche a voler dare rilevanza - il che non è ai fini della configurabilità del presupposto della risoluzione anticipata del contratto - alle n. 540 check list di contenuto negativo, le stesse ammontano ad una percentuale dello 00061% sul volume complessivo di pasti forniti!”* (pag.18 della comparsa conclusionale di *Parte_1*).

Parte_1, sostiene che non è ipotizzabile che un *“frammento di carta”, “un capello”, “un insetto rinvenuto adeso alla superficie di un panino”* possano concretare i profili del grave inadempimento legittimante la risoluzione di un rapporto d’appalto così complesso e chiede quindi che venga disposta una c.t.u. diretta ad accertare, fra l’altro, se la natura e quantità delle *“non conformità/contestazioni”* opposte dalla committente ai

fini della risoluzione contrattuale fossero idonee, sul piano della proporzione e rilevanza, a fondare un complessivo giudizio di inaffidabilità dell'appaltatrice nell'ambito della esecuzione del rapporto.

Ritiene il collegio che tale valutazione non abbia natura tecnica, bensì giuridica, e che spetti quindi al giudice, e non al tecnico, apprezzare la sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti della risoluzione per inadempimento, in particolare se lo stesso possa ritenersi di non scarsa importanza per la parte adempiente, in conformità al disposto dell'art. 1455 c.c.

L'interesse da prendere in considerazione ai fini della valutazione dell'importanza dell'inadempimento, ai fini della pronuncia costitutiva di risoluzione del contratto, è rappresentato dall'interesse che la parte inadempiente aveva o avrebbe potuto avere alla regolare esecuzione del contratto (in tal senso, Cass. ord. n. 4022/18).

In tale prospettiva, la questione non può essere vista esclusivamente sotto il profilo quantitativo, al fine di verificare se, in rapporto al numero delle forniture eseguite, la percentuale delle non conformità possa ritenersi apprezzabile. È importante infatti valutare anche la qualità della prestazione eseguita in rapporto all'interesse della parte adempiente.

Nella valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento occorre infatti considerare il peso oggettivo della mancata prestazione sull'equilibrio contrattuale e, dal punto di vista soggettivo, occorre considerare l'interesse del creditore alla prestazione mancata.

Nei propri atti la Controparte_1 dichiara che il proprio interesse è quello di fornire pasti buoni e sani agli utenti e infatti l'art. A.13.5 del capitolato prevede che “*reiterate inadempienze relativamente al rispetto delle caratteristiche dei prodotti da fornire, come indicate nella scheda tecnica*”, nonché “*gravi non conformità igienico-sanitarie, tali da pregiudicare la somministrazione in regime di sicurezza alimentare o che comunque possano pregiudicare il rapporto fiduciario con il fornitore*” possano addirittura dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

Va tenuto presente che nel caso di specie va dato particolare risalto alla necessità che vengano soddisfatti i requisiti attinenti alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute, dal momento che i destinatari finali del prodotto fornito da *Parte_1* sono bambini, anche dell'asilo nido, e soggetti deboli, come gli anziani e i disabili ospiti delle R.S.A. comunali e dei centri diurni.

Non a caso, il contratto espressamente prevedeva che dovesse essere garantito il “100 % *del quantitativo esente da cross-contamination*” e comunque *da altre materie prime non espressamente previste negli ingredienti indicati nelle schede tecniche di riferimento*” (art.7 del contratto allegato dalla convenuta quale doc. 4).

L'art. B.1 del capitolato statuiva inoltre che “*i prodotti devono essere conformi alle normative vigenti e possedere caratteristiche qualitative, igienico sanitarie e merceologiche conformi alle norme legislative nazionali e comunitarie*” e che “*Gli imballaggi devono essere integri, senza alterazioni manifeste. Le confezioni dei prodotti consegnati devono essere integre. I prodotti consegnati devono essere privi di corpi estranei, muffe, sudiciume, parassiti, difetti merceologici, odori, sapori, consistenza o colorazioni anomale*”.

Per questo la tesi di parte attrice, che sottolinea la marginalità degli episodi alla base delle contestazioni, se confrontati con la mole e il volume delle somministrazioni complessivamente effettuate da *Parte_1*, non può essere condivisa.

Laddove si considerino le esigenze specifiche di *Controparte_1*, sotto il profilo della salute e della sicurezza alimentare, non è possibile non attribuire rilevanza al quadro delineatosi a seguito dei controlli effettuati presso il laboratorio di *Parte_1* dal Comando *Org_1* di Torino e dall *Pt_3* di *Pt_3* quadro che indubbiamente ha inciso in maniera negativa sul rapporto di fiducia tra le parti.

In tale prospettiva, benché sul piano del valore economico complessivo delle prestazioni contrattuali gli episodi accertati possano ritenersi trascurabili, sul piano della qualità delle prestazioni, il cui *standard* deve ritenersi particolarmente elevato in considerazione

dell'interesse alla salute coinvolto, ogni singolo episodio attinente alla sussistenza dei requisiti igienico-sanitari assume una sua specifica e notevole rilevanza.

Se pertanto le violazioni relative a questioni quali i ritardi nelle consegne, o la grammatura del pane inferiore al dovuto, o errori di etichettatura - ove numericamente ridotte - possono ritenersi ininfluenti nell'economia del contratto, non altrettanto può affermarsi per "non conformità" consistenti nella presenza nel pane di insetti, sporcizia o altri corpi estranei quali fibre tessili, plastica e metallo.

Alla luce delle considerazioni che precedono, non possono essere condivise le osservazioni contenute nella relazione del prof. *Persona_10* allegata dall'attrice quale doc. 37, laddove si afferma che *"in Italia il settore della panificazione e dei prodotti da forno non prevede requisiti di legge circa la tolleranza/accettabilità quali-quantitativa dei corpi estranei nella materia prima"* e quindi si conclude che, in considerazione della occasionalità degli inconvenienti contestati e della scarsissima incidenza sul complessivo volume delle forniture effettuate, *"la tipologia/quantità delle NC contestate da Controparte_1 non siano idonee, sul piano della proporzione e della rilevanza, a fondare un complessivo stato di inaffidabilità da parte di Parte_1 nell'ambito della esecuzione del rapporto e, quindi, a determinare la risoluzione contrattuale"*.

Oltre al danno alla salute, le violazioni accertate comportano altresì un'indubbia lesione all'immagine della committente. Paiono pertanto giustificate sia l'apertura della procedura prevista dall'art. 108 D.lgs. n.50/2016 da parte di *Controparte_1* sia la manifestazione della volontà di sciogliersi dal vincolo contrattuale, comunicata con la nota del 9 marzo 2018 all'esito della stessa (doc. 18 di parte convenuta).

Non può essere infine condivisa la tesi di parte attrice, secondo la quale la committente non avrebbe potuto disporre in danno dell'impresa la risoluzione contrattuale senza violare il principio della proporzionalità, poiché la stessa aveva già consumato il proprio potere sanzionatorio nei confronti di *Parte_1* applicando penali per € 17.575,49.

Infatti la penale ha funzione risarcitoria e non si pone in alternativa al diritto di risolvere il contratto quando l'inadempimento non sia di scarsa importanza. Nei confronti del debitore inadempiente il contraente adempiente può quindi giovare della tutela offerta da entrambi gli istituti.

La domanda riconvenzionale con la quale la *Controparte_1* chiede di accertare il grave inadempimento di *Parte_1* alle obbligazioni contrattuali e dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 D.lgs. n.50/2016 e 1453 c.c. va pertanto accolta.

Ogni altra questione resta assorbita, a partire da quella relativa all'ammissibilità della domanda svolta per la prima volta all'udienza di prima comparizione delle parti dall'attrice, che ha chiesto la condanna di *Controparte_1* *“allo svincolo della fideiussione costituita con polizza n.2179402 emessa da CP_2 il 28.8.2017 per un importo di € 421.715,00 eventualmente con disapplicazione dell'art.11 del contratto in essere inter partes, poiché invalido e inefficace”*.

L'accoglimento della domanda riconvenzionale di *Controparte_1* comporta infatti il rigetto di tutte le domande dell'attrice, poiché è stata accertata la legittimità della scelta della committente di risolvere anticipatamente il contratto d'appalto, in considerazione del grave inadempimento della controparte.

5. Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al valore della causa e all'attività processuale svolta, sulla base dei parametri medi fissati dal D.M. 55/2014, conformemente alla nota spese della convenuta, previa riduzione degli importi relativi alla fase istruttoria, esauritasi con il deposito delle memorie previste dall'art. 183 sesto comma c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano – Sezione specializzata in materia di impresa - definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla *Parte_1* nei confronti della [...] *Controparte_1* e sulle domande riconvenzionali di quest'ultima, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:

- respinge le domande dell'attrice;
- accogliendo la domanda formulata in via principale dalla convenuta, dichiara risolto alla data del 9 marzo 2018, ai sensi degli artt. 108 D.lgs. 50/2016 e 1453 c.c., per grave inadempimento dell'attrice, il contratto n. 2017462113 stipulato fra le parti il 25 ottobre 2017 per la fornitura di pane e prodotti derivati per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro 3.372,00 per spese e in euro 31.000,00 per compensi, oltre 15% a titolo di rimborso forfetario, e accessori.

Così deciso in Milano, il 5 novembre 2020

Il Giudice estensore

Anna Bellesi

Il Presidente

Caterina Macchi